

1041510-51.2021.8.26.0224

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Energia Elétrica

Magistrado: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1041510-51.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1041510-51.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Energia Elétrica

Impetrante:

Central Brasileira de Produtos Alimentares - Cbpa

Impetrado:

Luís Eduardo Hess - Chefe da Delegacia Regional Tributária - Drt-13 de Guarulhos

CONCLUSÃO

Em 04/02/2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo. Eu, VAR, subscrevi.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Central Brasileira de Produtos Alimentares - Cbpa contra o Luís Eduardo Hess - Chefe da Delegacia Regional Tributária - Drt-13 de Guarulhos.

Alegou que está sujeito ao recolhimento do ICMS nas faturas de energia elétrica, todavia a cobrança tem sido realizada sobre o montante total previsto no Contrato de Reserva de Demanda ou Potência e não ao efetivamente consumido, requerendo que seja obstada a sua cobrança, bem como a repetição ou compensação dos valores pagos. O pedido liminar foi deferido (fl. 192).

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo requereu seu ingresso no feito como assistente (fl. 240).

A autoridade coatora prestou informações (fls. 243/276).

O Ministério Público pugnou pela sua não intervenção no feito (fls. 279/282).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto as preliminares arguidas.

Ab initio, destaco que a petição inicial não é inepta, porque não estão presentes no caso vertente quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil, §1º, cujo rol é taxativo.

Ora, os fatos foram adequadamente descritos e permitiram o exercício do contraditório, tanto que foram impugnados de forma específica nas informações prestadas e deles decorre de forma lógica o pedido, que é específico. O mais é questão de mérito.

As partes são legítimas e o interesse de agir está presente, pois possível verificar ato que o impetrante descreve ser irregular, descabendo qualquer reparo. Outrossim, o remédio utilizado permite corrigir eventual cobrança irregular, sendo possível sua compensação, o que não configura a obtenção de proveito econômico presente em ação declaratória.

Superadas tais questões, ao mérito.

A aquisição de energia elétrica para reserva, formalizada por contrato, não induz a transferência do bem adquirido, porque não se dá a tradição. Somente com a saída do bem adquirido do estabelecimento produtor e o ingresso no estabelecimento adquirente é que ocorre o fato gerador do ICMS.

Dessa forma, deve ser excluído do cálculo do ICMS o valor da demanda reservada de potência quando não houver o respectivo fornecimento.

Assim entendeu o Min. José Delgado no julgamento do Recurso Especial nº 222810/MG do C. STJ, em seu voto vencedor:

"O ICMS incide sobre o valor da energia elétrica que tenha sido concretamente consumida pela empresa, em virtude de que somente essa quantidade é que deve ser considerada como utilizada... Assim, como são nítidas in casu dois valores correspondentes a duas situações fáticas distintas (numa, fornecimento de energia, noutra, garantia de potência), e uma destas situações não chega a configurar o fato gerador do ICMS, somente caberá falar da incidência do imposto sobre o valor da operação de que resultou a entrega de energia e não daquela que resultou mera garantia de potência.... Ora, o ICMS não grava o negócio jurídico da compra e venda (não é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do consumidor."

O E. Tribunal de Justiça não é diferente:

AÇÃO ORDINARIA - ICMS Energia Elétrica Contrato de demanda reservada de potência - Legitimidade "ad causam" da consumidora final reconhecida, conforme REsp nº 1.299.303/SC Fato Gerador - Base de cálculo do tributo estadual que também inclui a parcela relativa à demanda reservada ou contratada - Inadmissibilidade - Fato gerador do ICMS que somente ocorre no momento em que o produto é entregue ao consumidor - A hipótese de incidência tributária é a circulação da mercadoria, no caso, sua utilização efetiva pelo consumidor Juros moratórios que correrão a partir do trânsito em julgado da ação, nos termos do art. 167, par. único, do CTN Correção monetária a contar a partir de cada recolhimento indevido (Súmula 162, STJ) - Recurso voluntário da ré não provido e acolhido em parte o reexame necessário tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios e a correção monetária a contar a partir de cada recolhimento indevido (Súmula 162, STJ) - Precedentes desta E. Corte. (Relator(a): Rebouçasde Carvalho; Comarca: SãoPaulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 11/03/2015)

Por fim, foi editada a Súmula nº 391 que prevê que "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada."

Ante o exposto, CONCEDO a segurança e extingo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC para declarar a abstenção da autoridade coatora em exigir o pagamento do ICMS sobre a energia elétrica reservado, devendo incidir tão somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, bem como o dever de compensar os valores indevidamente recolhidos a maior.

Custas pelo impetrado.

Sem condenação em honorários.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.

Guarulhos, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA